

1501822-35.2021.8.26.0544

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Renata Marques de Jesus

Comarca: Francisco Morato

Foro: Foro de Francisco Morato

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 26/09/2022

... os envolvidos antes dos fatos. O tráfico é no muro da escola do Jardim Silvia. Não havia outras pessoas no local, pelo que se recordou (fls. 173).

Na mesma esteira o depoimento extrajudicial do também policial civil Abel Gonçalves de Souza que, em juízo, informou que o local é conhecido como ponto de venda de drogas. O trafico ocorre atraso do muro da escola. Viram dois ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Francisco Morato

Foro de Francisco Morato

1ª Vara

Rua João Mendes Júnior, 626, Francisco Morato - SP - cep 07910-220

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501822-35.2021.8.26.0544 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501822-35.2021.8.26.0544

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VICENTE LEONARDO APARECIDO DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Renata Marques de Jesus

Vistos.

VICENTE LEONARDO APARECIDO DA SILVA, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso nas penas do artigo 33, caput, c.c. artigo 40, incisos III e VI, ambos da Lei nº 11.343/06, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j" do Código Penal (estado de calamidade pública), porque no dia 27 de julho de 2021, por volta das 12 horas, na Rua Vinte e Um, altura do número 80, bairro Jardim Silva, nesta cidade e Comarca de Francisco Morato, trazia consigo e tinha em depósito, para fins de comercialização, envolvendo e visando atingir o adolescente N.C.S., nas imediações de estabelecimento de ensino, 09 (nove) porções de "maconha" (cannabis Sativa L.), com peso líquido aproximado de 37,2g (trinta e sete gramas e duas decigramas); 44 (quarenta e quatro) porções de cocaína, com peso líquido aproximado de 32,68g (trinta e duas gramas e sessenta e oito centigramas); e 32 (trinta e duas) porções de crack, com peso líquido aproximado de 8,96g (oito gramas e noventa e seis centigramas), substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (fls. 1/3).

Preso em flagrante delito (fls. 4), foi-lhe concedido o benefício da liberdade provisória por ocasião da audiência de custódia (fls. 64/65) e expedido o competente alvará de soltura (fls. 66/68).

Notificado (fls. 126), o réu apresentou defesa prévia (fls. 129/136) e a denúncia foi recebida (fls. 146/147).

Durante a instrução processual foram ouvidas duas testemunhas (fls. 173 e 174). O réu não compareceu ao ato, sendo declarado revel (fls. 170/172). Mídia arquivada.

Em alegações finais o Ministério Público pugnou pela condenação nos termos da denúncia, observando a inexistência de óbice ao redutor do § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06 e possibilidade de fixação de regime inicial semiaberto (fls. 170/172). A Defesa, por sua vez, requereu, em resumo, a absolvição em razão da ausência de provas e, subsidiariamente, a fixação de pena mínima, reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06 e fixação de regime inicial aberto (fls. 175/185).

É o relatório.
Fundamento e decido.

À luz das provas carreadas aos autos, a pretensão inicial merece prosperar.

A materialidade restou comprovada ante o auto de prisão em flagrante (fls. 4/8), boletim de ocorrência (fls. 9/12), auto de exibição e apreensão (fls. 13/14), além do exame químico-toxicológico de fls. 167/169, que constatou as presenças de tetrahydrocannabinol (THC), crack e de cocaína nas amostras analisadas.

A autoria também é certa, corroborada pela própria confissão do acusado, ainda que extrajudicial.

Perante a autoridade policial o réu confessou a prática do delito, narrando que, movido por dificuldades financeiras, iniciou a venda de drogas e, no dia dos fatos, efetuou a venda de um pino de cocaína para um rapaz. Após, foi abordado pelos policiais descaracterizados (fls. 8). Em juízo, todavia, não compareceu, sendo declarado revel (fls. 170/172).

Antônio Alexandre Barbosa, policial civil que participou da ocorrência, afirmou que durante o serviço policial a fim de coibir o tráfico de drogas realizaram diligências no bairro J. Silvia, onde montaram uma observação velada utilizando viatura descaracterizada e, do alto de um morro, nos fundos da escola J. Silvia II, avistaram dois indivíduos e em situações que indicava ser de venda de drogas, sendo que um entregou algo e, em seguida, recebeu um pequeno objeto. Diante dos fatos foram ao local e abordaram os dois indivíduos e, com o adolescente N.C.S, encontraram um pino de cocaína e dez reais e, indagado, afirmou ser usuário de drogas e que tinha comprado a droga de outro rapaz. O outro rapaz foi identificado como VICENTE, ora réu, que estava com uma sacola plástica em suas mãos e, durante a revista no interior da sacola, encontraram os entorpecentes e valores apreendidos. Indagado, o réu confessou a traficância (fls. 5). Em juízo contou que o local é conhecido pela venda de drogas. Já foram feitas prisões em outras datas. Observaram a distância a movimentação dos rapazes. Ficaram por volta de 10 min, no máximo, e viram a necessidade de abordar. Eles não perceberam que eram policiais. Com o maior foi encontrada uma sacola nas mãos com entorpecentes e R\$ 62,00 em dinheiro trocado. Como menor foi encontrada uma porção de cocaína e R\$ 100,00. O adolescente disse ser usuário e ter ido comprar do réu. O maior confessou a traficância. Não conhecia os envolvidos antes dos fatos. O tráfico é no muro da escola do Jardim Silvia. Não havia outras pessoas no local, pelo que se recordou (fls. 173).

Na mesma esteira o depoimento extrajudicial do também policial civil Abel

Gonçalves de Souza que, em juízo, informou que o local é conhecido como ponto de venda de drogas. O tráfico ocorre atrás do muro da escola. Viram dois indivíduos próximos um ao outro e um tirou algo da sacola e entregou ao outro. Realizaram a abordagem. O maior estava com uma sacola na mão, com os três tipos de drogas e dinheiro. Com o adolescente um punho de cocaína e dinheiro. O maior assumiu estar a serviço do tráfico e o menor que tinha comprado para consumo diretamente do acusado. Não conhecia os envolvidos antes dos fatos. Estavam somente os dois no local. Já efetuaram outras prisões por tráfico no local (fls. 174).

O adolescente N.C.S., em solo policial, contou que é usuário de drogas e na data dos fatos comprou uma porção de cocaína do réu, pagando dez reais e, após, foram abordados por policiais civis descaracterizados (fls. 7). Em juízo não compareceu, sendo dispensada a sua oitiva (fls. 170/172).

Há de se levar em conta que o acusado e os policiais civis não se conheciam até então, de forma que estes não tinham motivos para acusá-lo leviana e gratuitamente.

É importante salientar que a lei penal não furta valor ao testemunho dos agentes de segurança, na medida em que não os dispensa do compromisso de dizer a verdade e nem os poupa do crime de falso testemunho caso venham a sonegar ou adulterar os fatos. Aliás, nem teria sentido conferir-lhes a lei determinada tarefa para depois, quando viessem prestar contas de sua atuação, negar-lhes valor aprioristicamente, por preconceituosa admissão de que não dizem a verdade:

“É assente nesta Corte o entendimento de que são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta Corte” (STJ, Sexta Turma, AgRg no Ag 1158921/SP, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, julg. 17/05/2011, DJe 01/06/2011);

“O depoimento de policial obedece os mesmos princípios aplicados ao restante das pessoas, não havendo que se falar em suspeição ou inidoneidade considerando-se somente a sua condição funcional” (TJSP, RT 752/586);

“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestado em juízo sob garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar – tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam, com outros elementos probatórios idôneos” (STF, HC nº 74.608-0, Rel. Min. Celso de Mello, j. 18/02/97, DOU de 11/04/97, p. 189);

“Não se pode presumir em policiais ouvidos como testemunhas a intenção de incriminar falsamente o acusado da prática de crime contra a saúde pública na modalidade de tráfico de entorpecente por asseverarem que a substância tóxica foi encontrada em poder daquele. A presunção, ao contrário é de idoneidade destas testemunhas, ainda mais quando os seus depoimentos são seguros precisos e uniformes desde a sede inquisitorial e não há qualquer razão concreta de suspeição” (TJSP, RT 614/275);

“Os policiais não são proibidos de prestar depoimento nos processos de cuja fase policial tenham participado, seja efetuando a prisão do agente, seja apreendendo o objeto do crime. De outro lado, a declaração de inidoneidade é específica e não genérica, não podendo abranger toda uma categoria de pessoas, devendo ser alegada e demonstrada em cada caso” (TJMG, RT 604/407).

A partir do contexto probatório extrai-se que as testemunhas prestaram depoimentos coesos e convergentes, reafirmando as declarações prestadas na fase policial, tornando seguro um decreto condenatório.

E, não demonstrou a Defesa eventual motivo que os policiais civis teriam para mentir em juízo deixando, assim de se desincumbir de seu ônus (artigo 156, do Código de Processo Penal), destacando que eventuais e pequenas contradições entre os depoimentos, sequer existentes na hipótese, não são capazes de infirmar a lisura do trabalho policial. Nesse sentido:

“PROVA - Pequenas divergências entre os relatos das testemunhas - Irrelevância - Validade. As pequenas contradições na prova decorrem das próprias imperfeições do psiquismo humano, agravadas, em geral, pelas condições em que a prova é realizada. Assim, de se desconfiar do testemunho demasiado perfeito, sendo, sim, importante, verificar se, embora discrepantes em detalhes mínimos, concordam os depoimentos nos pontos essenciais, quanto às circunstâncias decisivas do fato” (TACrimSP - Ap. nº 583.153/2 - 7ª Câ. - Rel. José Habice - J. 05.04.90 - RJDTACRIM 6/78).

A Defesa tenta, em vão, diminuir o valor dos depoimentos dos policiais, o que não se sustenta diante do quadro probatório existente e dos elementos de convicção formados. Nesse ponto, é preciso ficar claro que a inexistência de testemunhas civis e 'eventuais compradores' no ato da prisão em flagrante não o invalida, cumprindo ressaltar que em delitos da espécie, como cediço, ainda que populares presenciem a atividade criminosa, estes não querem se identificar com medo de represálias por parte dos criminosos.

Dentro desse quadro, os depoimentos das testemunhas ouvidas sob o crivo do contraditório, repita-se, foram harmônicos e convergentes, corroborando a própria confissão, levando à certeza da autoria.

Sendo assim, a variedade, a quantidade e nocividade das drogas apreendidas, a forma como embaladas (fls. 40/42), o fato de envolver e visar atingir o adolescente, ser o local da apreensão próximo da escola J. Silvia II (fls. 35/36), bem como o depoimento seguro prestado pelas testemunhas, corroborado pela própria confissão extrajudicial, levam à certeza de que o réu traficava drogas na ocasião, impondo-se a condenação com as causas de aumento do artigo 40, III e VI, da Lei nº 11.343/06, pois demonstrado que a prática do crime ocorreu nas imediações de estabelecimento de ensino e, ainda, envolvendo e visando atingir o adolescente N. C.S.

Destaca-se que o crime de tráfico de entorpecente é de mera conduta, bastando, para a sua consumação, a prática de qualquer um dos núcleos verbais do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, independentemente da concretização ou não da entrega ao destinatário, pelo que a simples conduta do réu, consistente em “trazer consigo” as substâncias entorpecentes, já são suficientes para caracterização do delito:

“Nunca é demais lembrar, de outro lado, que é desnecessária a prova de ato de comércio, bastando que o agente traga consigo ou mantenha em depósito a droga para esta destinação, ainda que futura, na medida em que a consumação não exige resultado” (TJSP - Apel. Crim. nº 990.09.088010-4 - 5ª Câmara Criminal - Campinas - v.u. - j. 03.09.09 - Rel. Des. Pinheiro Franco).

No mesmo sentido:

“O crime de tráfico de entorpecentes é configurado ainda que não haja venda de tóxico, mas evidenciada somente a posse do produto destinado a consumo de outrem. Configurando crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da droga a terceiro, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública. É condenável a simples possibilidade de distribuição (gratuita ou onerosa) do entorpecente” (RT 776/663);

"Não é indispensável à prova efetiva do tráfico para a formação de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente envolvido" (RT 729/542);

"Cabe ressaltar que para a caracterização do crime de tráfico de entorpecentes não é necessária a prova flagrante do comércio ilícito, sendo suficientes os elementos indiciais apurados no caso concreto, bem como as circunstâncias da prisão para evidenciar tal atividade ilícita". (TJ/SP - Apel. Crim. nº 990. 09.235417-5 - 14ª Câmara Criminal - v.u. - j. 11.03.10 - Rel. Des. Fernando Torres Garcia).

Ressalta-se que a considerável quantidade e variedade de entorpecente, além da forma como se deu sua apreensão demonstram a traficância e não autorizam eventual classificação da conduta como simples consumo pessoal (artigo 28, da Lei nº 11.343/06):

"DESCCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO DE USO - Inadmissibilidade - Quantidade e diversidade de entorpecentes - Conjunto probatório suficiente para ensejar o decreto condenatório - Inexistência de prova segura que autorizasse decretar nova definição jurídica da conduta." (TJSP, 16ª Câmara de Direito Criminal, Apelação nº 990.08.080898-2, Des. Rel. Leonel Costa, j. 28/04/09).

E o fato de o acusado eventualmente afirmar que é usuário de droga, o que não se vislumbra, não é suficiente para a desclassificação do delito de tráfico, sendo, repita-se à exaustão, a condenação de rigor. Vale destacar, ainda, que a condição de usuário não é incompatível com a de traficante:

"(...) a mera condição de usuário ou dependente, por si só, não possui o condão de excluir a culpabilidade pelo narcotráfico, porquanto, em muitos dos casos, os usuários se valem dessa mercancia ilícita para provar o sustento do próprio vício, de tal forma, que uma conduta nem sempre pode excluir a outra." (TJSP, AC nº 0000318-44.2016.8.26.0544, Rel. Des. França Carvalho, j. 05/04/2018).

"A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente há hipótese vertente, em que ambas se mesclam num mesmo agente, preponderando a última, de maior gravidade" (TJSP RJTJSP 101/498);

"Importante consignar que o fato de o acusado ter declarado que era usuário de drogas não afasta sua condição de traficante, uma vez que os usuários, frequentemente, também passam a comercializar entorpecentes, justamente para obter dinheiro e garantir o vício e o próprio sustento, acrescentando-se, por oportuno, que uma conduta não exclui a outra" (TJSP; 9.ª Câmara Criminal, Ap. n.º 0001866-59.2015.8.26.0635, Rel. Sérgio Coelho, j. em 31.03.2016);

"Nenhuma incompatibilidade existe entre o tráfico de entorpecente e o vício. Ao contrário. Em regra, vivem associados" (RT 411/104).

Cabe observar, nesse passo, que a apreensão de não desprezível quantidade de substância entorpecente em poder do agente, além da circunstância de estar separada em unidades diferentes ou dividida em porções, conduz à segura conclusão de que se destina ao comércio ilícito, e não ao uso próprio.

Por fim, restou comprovada a presença da causa de aumento constante no art. 40, III, da lei nº 11.343/06.

De fato, o conjunto probatório demonstra que o acusado traficava drogas nas imediações de estabelecimento de educação, conforme relatado pelas testemunhas e croqui elaborado pela autoridade policial (fls. 35/36). Assim, resta caracterizada a majorante:

"Apelação. Tráfico de drogas. Art. 33, caput, c.c. art. 40, inciso III, da Lei 11.343/06. Materialidade comprovada. Autoria indubitosa considerando o depoimento dos policiais responsáveis pelo flagrante. Crime que foi cometido nas imediações de estabelecimento de ensino, fato que impede o afastamento do art. 40, III, da mencionada lei. Recurso não provido. Sentença mantida." (TJSP; Relator: Reinaldo Cintra; 7ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 24/05/2017; Data de registro: 29/05/2017);

"EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRANSPORTE PÚBLICO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. NATUREZA. PROGRESSÃO DE REGIME. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. PREJUÍZO À IMPETRAÇÃO, NO PONTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. A utilização do transporte público como meio para a prática do tráfico de drogas é suficiente para o reconhecimento da causa especial de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/06, porque a majorante é de natureza objetiva e aperfeiçoasse com a constatação de ter sido o crime cometido no lugar indicado, independentemente de qualquer indagação sobre o elemento anímico do infrator. Precedente. 2. O Plenário do Supremo Tribunal decidiu pela inconstitucionalidade da vedação contida nos art. 33, § 4º, e 44 da Lei 11.343/06, não admitindo seja subtraído do julgador a possibilidade de promover a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos quando presentes os requisitos inseridos no art. 44 do Código Penal. 3. A progressão de regime já deferida à Paciente torna prejudicada, no ponto, a impetração. 4. Ordem parcialmente concedida, prejudicado o pedido de progressão de regime." (STF. HC 109411. Ministra Cármen Lúcia. 1ª Turma, 11.10.2011) – grifos nossos.

"Dessarte, ao contrário do que sustenta a impetrante, para a incidência da majorante prevista no art. 40, inciso III, da Lei n.º 11.343/2006 não é necessária a efetiva comprovação de mercancia nos referidos locais, ou mesmo de o comércio visava a atingir os estudantes, as pessoas hospitalizadas ou os usuários do metrô, sendo suficiente que a prática ilícita tenha ocorrido em locais próximos, ou seja, nas imediações de tais estabelecimentos, diante da exposição de pessoas ao risco inerente à atividade criminosa da narcotraficância." (STJ, Sexta Turma, HC 310.467/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 26/05/2015, DJe 02/06/2015)

Por fim, também restou comprovada a presença da causa de aumento constante no art. 40, VI, da lei n.º 11.343/06.

De fato, o conjunto probatório demonstra que o acusado traficava drogas, apresentou-se ao adolescente como "vendedor" e a ele entregou o entorpecente. Assim, resta caracterizada a majorante:

"Note-se a previsão feita pela redação do tipo derivado: envolver (trazer o menor para cenário das drogas, sob qualquer pretexto) ou visar (ter o menor como meta para o uso de drogas). Por isso, o menor pode ser participante ou vítima do tráfico ilícito de entorpecentes" (Guilherme de Souza Nucci, in Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, Editora Revista dos Tribunais, 5ª edição, p. 389).

Destarte, comprovadas a autoria e a materialidade, inexistindo causa de exclusão da ilicitude, a ação penal é procedente, amoldando-se a conduta praticada pelo réu à figura típica prevista no artigo 33, "caput", c.c. artigo 40, III e VI, ambos da Lei n.º 11.343/06.

Passo a dosar a pena:

Sopesados os elementos norteadores do art. 59, do Código Penal e em observância ao disposto no artigo 42, da Lei n.º 11.343/06, que autoriza que o magistrado considere

na primeira fase de dosimetria a natureza do entorpecente, a quantidade, a personalidade e a conduta social do agente, de rigor a fixação da pena-base acima do mínimo legal (v.g. STF, HC nº 96.655, rel. Min. Cármen Lucia; STF, HC nº 107.784, rel. Min. Ricardo Lewandowski; STJ, HC nº 237.837, rel. Min. Laurita Vaz; STJ, HC nº 235.524, rel. Min. Jorge Mussi; STJ, HC nº 223.447, rel. Min. Laurita Vaz; STJ, HC nº 179.086, rel. Min. Gilson Dipp). No mesmo sentido:

"REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. ELEVADA QUANTIDADE DO ENTORPECENTE APREENDIDO.

POSSIBILIDADE. AUMENTO PROPORCIONAL. 1. Na fixação da pena-base de crimes previstos na Lei n. 11.343/2006, como ocorre na espécie, deve-se considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei de Drogas. 2. Na espécie, a reprimenda de piso acima do mínimo legal, em razão da natureza e a excessiva quantidade do estupefaciente apreendido, encontra-se devidamente justificada e proporcional às especificidades do caso versado. [...] 2. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no AREsp 585.375/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 16/3/2017, DJe 27/3/2017);

O réu é primário e não possui antecedentes criminais (fls. 103/105), contudo, na hipótese, foi localizado com "crack" e cocaína, entorpecentes de alto poder viciante, que causam dependência física e psíquica, mesmo que utilizados apenas uma única vez, motivo que enseja uma maior reprimenda, pois seria desarrazoado punir aquele que vende "maconha" na mesma medida daquele que vende entorpecente altamente viciante, que além de causar um impacto muito maior na saúde do usuário, ainda repercute na sociedade e na família, somado ao fato de corroborar com a prática delitiva daqueles que não possuem condições financeiras de sustentar o vício.

Segundo o entendimento de Guilherme de Souza Nucci, "A Lei de Drogas baseia-se, principalmente, na punição de crimes de perigo abstrato, o que justifica destacar, como elementos preponderantes na individualização da pena, dentre outros, a natureza e quantidade da substância ou do produto. É natural supor que, quanto maior for a quantidade de drogas ilícitas em circulação, maior será o perigo em relação à saúde pública. Ademais, quanto mais forte for a droga ilícita, igualmente, mais grave será a consequência em virtude de sua utilização. Estes fatores, portanto, podem e devem ser levados em conta pelo magistrado" (in Leis penais e processuais penais comentadas, 4ª edição, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 378)

No mesmo sentido, defende Renato Brasileiro de Lima que "Como se trata de crime contra a saúde pública, quanto mais nociva a substância ou quanto maior a quantidade de droga apreendida, maior será o juízo de censura a recair sobre a conduta delituosa. De fato, não se pode equiparar a conduta daquele que é preso com um quilograma de maconha com a daquele que é preso com um quilograma de cocaína, já que esta droga tem um caráter viciante e destrutivo bem mais elevado que aquela" (in Legislação criminal especial comentada, 2ª edição, JusPODIVM, 2014, p. 787).

Registre-se que a cocaína é considerada um dos entorpecentes mais nefastos e viciantes, o que traz maiores danos à saúde pública, sendo de rigor a fixação da pena-base acima do mínimo legal, por ser proporcional à quantidade e natureza.

Assim, ponderando tal circunstância (natureza), fixo a pena-base com o acréscimo de 1/6 (um sexto), ou seja, em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Quanto à fração a ser aumentada, vale destacar não haver previsão legal valorando o quantum, ficando a critério do magistrado analisando o caso concreto: "o magistrado fixa a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto" (STJ, AgRg no REsp nº 143.071/AM, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 6/5/2015).

Prosseguindo, nos termos do artigo 68, do Código Penal, verifico presente a atenuante da confissão (artigo 65, III, "d", do Código Penal), razão pela qual retorno a reprimenda imposta ao seu mínimo, sendo nesta fase vedada a fixação abaixo do mínimo legal (Súmula 231, do STJ), perfazendo, assim, 5 (cinco) anos e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Ainda, deve ser reconhecida a agravante prevista no art. 61, II, alínea "j", do Código Penal, na medida em que o crime foi cometido durante o período da pandemia causada pelo novo coronavírus (COVID-19), quando já estava decretado o estado de calamidade pública, com recomendação do isolamento social e outras medidas públicas (Decreto Estadual nº 64.879/20 e Decreto Legislativo nº 6/2020), o que reduz a vigilância.

A prática de crime em cenário no qual toda a população passa por privações e incertezas e em meio a diversas recomendações de recolhimento domiciliar e restrição de atividades de toda ordem é ainda mais reprovável e merece resposta penal diferenciada. A situação atualmente vivida é excepcional e, sem dúvida, do conhecimento de todos, motivo pelo qual aumento a pena em 1/6 (um sexto), estabelecendo-a em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa:

"TRÁFICO DE ENTORPECENTES PRIVILEGIADO. APELO MINISTERIAL. PLEITOS DE RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, "J", DO CÓDIGO PENAL, E DE AFASTAMENTO DO PRIVILÉGIO, COM READEQUAÇÃO DAS PENAS. NECESSIDADE. RECURSO PROVIDO. Base fixada em 1/6 acima do mínimo legal, valoradas como negativas as circunstâncias relacionadas à natureza da droga (cocaína, acondicionada na forma de tijolos) e do seu transporte entre cidades. Na segunda etapa, pedido ministerial acolhido, para reconhecimento da agravante da prática de crime em ocasião de calamidade pública (art. 61, II, "j", do CP). Prática do crime durante a pandemia de COVID-19. Lei não prevê nenhuma condicionante finalística ou modal para que a agravante incida. Mantido o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, as penas ainda foram reduzidas em 1/10, dada a preponderância da atenuante (art. 67, CP). A quantidade dos entorpecentes apreendidos (quase dois quilogramas de cocaína) e seu alto valor no comércio clandestino de entorpecentes demonstram envolvimento do apelado em atividades criminosas, impedindo, portanto, a incidência do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, o qual fica afastado. Penas redimensionadas para 5 anos e 3 meses de reclusão e 524 dias-multa. REGIME PRISIONAL. Imposição do regime inicial fechado, ante a pena concretizada e as circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 33, parágrafo 3º, do Código Penal), a par da gravidade concreta do delito praticado. BENEFÍCIOS LEGAIS. Incabível a concessão de sursis ou de substituição da pena corporal por restritivas de direitos, ante a quantidade de pena concretizada, Recurso ministerial provido para, afastado o privilégio e reconhecida a agravante do art. 61, II, "j", do CP, redimensionar as penas do apelado, bem como fixar-lhe o regime inicial fechado." (TJSP; Apelação Criminal 1522780-54.2020.8.26.0228; Relator (a): Gilda Alves Barbosa Diodatti; 15ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 28/04/2021; Data de Registro: 28/04/2021) - grifos nossos

Na terceira fase de dosagem da pena majoro a reprimenda em 1/6 (um sexto) em razão da prática do crime ter sido cometido nas imediações de estabelecimento de ensino (artigo 40, III, da Lei nº 11.343/06) e fixo-a em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Majoro, também na fração de 1/6 (um sexto), pois a prática do crime envolveu e visou atingir adolescente, na forma do artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, fixando-a em 7 (sete) anos, 11 (onze) meses e 8 (oito) dias de reclusão e pagamento de 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa.

Presente, porém, a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, diminuo a pena em 1/2 (metade), resultando em 3 (três) anos, 11 (onze) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão e pagamento de 396 (trezentos e noventa e seis) dias-multa.

Ainda que se reconheça seja o réu primário e não exista prova de que se dedique às atividades delituosas, nem íntegra organização criminosa, justifica-se a diminuição apenas em 1/2 (metade) em razão da variedade e não desprezível quantidade da droga encontrada em seu poder (TJSP, Apelação nº 01049362.3/2, Des. Rel. Silveira Lima, j. 12/09/2007).

Esta pena torna-se definitiva, tendo em vista a inexistência de outras causas de aumento e de diminuição.

O valor do dia-multa deve ser calculado nos termos do artigo 43, da Lei nº 11.343/06, sendo fixado em um trinta avos do salário mínimo vigente à época do pagamento, tendo em vista a situação econômica do acusado.

No entanto, em que pese outro fosse o entendimento pessoal desta magistrada, curvou-me à decisão proferida no Habeas Corpus Coletivo nº 596.603/SP, do C. Superior Tribunal de Justiça (Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz) e fixo o regime aberto como modo inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade.

Afigura-se, no entanto, descabido falar em substituição da pena corporal por restritivas de direitos ou "sursis", porque não recomendáveis (artigos 44, III, e 77, II, do Código Penal), destacando que o crime foi cometido nas imediações de estabelecimento de ensino e, ainda, envolvendo e visando atingir o adolescente-comprador.

Ademais, cuida-se de crime de natureza grave, de acentuada reprovabilidade e cujas circunstâncias e consequências impedem a substituição, sob o risco de a retribuição estatal ao ilícito tornar-se inócua. Em outras palavras, nem seria razoável que o réu, condenado por traficar entorpecentes extremamente nocivos à saúde humana, a desestabilizar o seio familiar e a vida em sociedade, venha a receber tratamento similar àquele agente que perpetra um delito de menor potencial ofensivo (TJSP, Apelação Criminal nº 1501495-39.2019.8.26.0228, 4ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Ivana David, j. 15/09/2020).

Vale lembrar que o chamado tráfico "privilegiado", previsto no §4º, do artigo 33, da Lei de Drogas, não é um tipo penal autônomo menos grave, mas sim causa de diminuição de pena, sendo certo que a minorante não tem o condão de alterar o próprio tipo penal do tráfico de drogas que, frisa-se, é crime grave.

A substituição, se deferida, faria com que a pena privativa de liberdade aplicada perdesse consideravelmente a sua força retributiva e preventiva, diante do gravíssimo delito de tráfico de drogas, levando em conta as especificidades do caso, como quantidade das drogas apreendidas, dedicação do réu a essa atividade criminosa, envolvimento de adolescente na conduta praticada nas proximidades de estabelecimento de ensino e montante da pena.

Ademais, não vislumbro socialmente recomendável a reinserção de traficantes ao convívio social, indicando-lhes instituições públicas (escolas, repartições públicas, centros de saúde etc) para prestar serviços comunitários. Ausente, portanto, o requisito do inciso III, do art. 44 do Código Penal (suficiência da substituição).

O crime, frisa-se, é de especial gravidade, consistindo em causa ou consequência da prática de outros tão ou mais graves e intimamente ligados com a criminalidade violenta e com a desestruturação de inúmeras famílias. Os efeitos nocivos do crime

de tráfico de drogas acarretam profundas feridas na sociedade atual, revelam a postura indiferente adotada pelo agente em relação à saúde pública e ao bem estar social, e as nefastas consequências de seus atos vão de encontro com o requisito previsto pelo inciso III, do artigo 44, do Código Penal, qual seja, "os motivos e circunstâncias do crime indicarem que essa substituição seja suficiente".

Assim, embora tenha sido praticado sem violência ou grave ameaça, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não é cabível na espécie, uma vez que seria insuficiente à prevenção e repressão do ilícito penal.

Nesse sentido:

"(...) Por sua vez, a quantidade, diversidade e natureza das drogas constituem circunstâncias concretas que desnudam um elevado grau de culpabilidade, a impor o regime inicial fechado para a pena privativa de liberdade. O que também obsta a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito (artigo 44, I e III, do Código Penal), benefício, de resto, incompatível com a quantidade das sanções.(...)" (TJSP, 14ª Câmara de Direito Criminal, Apelação Criminal nº 1503722-19.2017.8.26.0536, Rel. Laerte Marrone, j. 30/01/2020)

"(...) a gravidade concreta da conduta do apelante, decorrente da quantidade de droga capaz de atingir um número não desprezível de usuários, revela a sua elevada danosidade social, a revelar óbice à substituição da pena corporal por restritivas de direitos, máxime porque estas não se mostram suficientes e socialmente recomendáveis (art. 44, III, CP). (...)" (TJSP, 13ª Câmara de Direito Criminal, Apelação Criminal nº 0000208-34.2016.8.26.0483, Rel. Moreira da Silva, j. 03/08/2017)

"(...) No entanto, com a devida vênia, o traficante, seja de pequeno, de médio ou de grande porte, não tem mérito para inicialmente cumprir a pena infligida de outra forma que não encarcerado. Ora, não se mostra razoável que o traficante, condenado por delito equiparado a hediondo (artigo 5º, inciso XLIII da Constituição Federal) venha a receber tratamento similar ao agente que perpetra um delito de menor potencial ofensivo. Em suma, não se mostra adequada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito em casos de tráfico de entorpecente, uma vez que tal medida atenta contra a efetividade do processo penal na aplicação do justo concreto, atingindo frontalmente o caráter retributivo da reprimenda e a dimensão material ou substancial do due process of law. (...) E, na espécie, como foram apreendidas 16 gramas de cocaína, droga de grande potencial ofensivo, a aplicação de pena alternativa encontra óbice na exegese do artigo 44, III do Código Penal, sendo insuficiente como resposta à culpabilidade do agente, aos motivos e às consequências do exercício da mercancia" (TJSP, Habeas Corpus nº 0049710-72.2012.8.26.0000, 4ª Câmara Criminal, Rel. Des. Euvaldo Chaib).

Ante o exposto e tudo mais que dos autos consta JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar VICENTE LEONARDO APARECIDO DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 33, "caput" c.c. §4º c.c. art. 40, III e VI, ambos da lei nº 11.343/06, fixando-lhe a pena privativa de liberdade de 3 (três) anos, 11 (onze) meses e 19 (dezenove) dias reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 396 (trezentos e noventa e seis) dias-multa, fixados no valor mínimo legal.

O réu poderá recorrer em liberdade, até porque assim respondeu ao processo e foi fixado regime inicial aberto, não havendo, ainda, razões para que seja decretada a sua prisão cautelar:

"I. Tendo o réu respondido ao processo em liberdade, o seu direito de apelar nesta condição somente lhe pode ser denegado se evidenciadas quaisquer hipóteses previstas no art. 312 do CPP, quando da prolação da sentença (Precedentes). II. Inexiste motivação convincente se não foi indicado qualquer fato novo que

justifique a expedição de mandado de prisão (Precedentes). (...) Writ concedido." (STJ, 5ª Turma, HC nº 51609/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 04/05/06, DJ 19/06/06, p. 161);

"1. A necessidade de recolhimento dos réus à prisão pra recorrer deve estar devidamente motivada, sendo insuficiente a mera consideração acerca do caráter hediondo ou da gravidade do delito. Precedentes do STJ e do STF. 2. Ordem concedida para garantir aos pacientes o direito de apelar em liberdade, expedindo-se alvará de soltura se por outro motivo não estiverem presos." (STJ, 5ª Turma, HC nº 46035/BA, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 15/12/05, DJ 10/04/06, p. 243).

Autorizo a incineração das drogas, nos termos dos artigos 50, §§ 3º e 4º e 72, ambos da Lei de Tráfico, destruindo-se amostras guardadas para contraprova. Comunique-se nos termos dos art. 524-A, § 2º, e 525, das NSCGJ, caso tal providência ainda não tenha sido adotada.

Nos termos dos artigos 63, I e § 1º, e 64, ambos da Lei nº 11.343/06, decreto o perdimento da quantia apreendida em poder do acusado (fls. 13/14), pois decorrente da prática do crime em questão. Oficie-se, após comprovação pela autoridade policial do depósito do referido valor nos autos, caso tal providência ainda não tenha sido adotada.

Na forma do artigo 804 do Código de Processo Penal e do artigo 4º, § 9º, alínea "a", da Lei nº 11.608/03, condenado, o réu arcará com as custas processuais:

"o réu, ainda que beneficiário da assistência judiciária gratuita, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, ficando, contudo, seu pagamento sobrestado, enquanto perdurar seu estado de pobreza, pelo prazo de cinco anos, quando então a obrigação estará prescrita, conforme determina o art. 12 da Lei 1.060/50. Precedentes. A isenção somente poderá ser concedida ao réu na fase da execução do julgado, porquanto esta é a fase adequada para aferir a real situação financeira do condenado, já que existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação" (REsp. 400.682, Rel. Min. Laurita Vaz, DJ 17/11/ 2003,). No mesmo sentido: REsp. 262.961, Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, DJ 17.06/2002; REsp. 263.021, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ 18.03/2002 e REsp. 81.304, Rel. Min. Edson Vidigal, DJ 14/09/98. Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se provimento ao recurso." – grifos nossos (TJSP, 4ª Câmara de Direito Criminal, Apelação nº 0008903-30.2009.8.26.0189, Relator Des. Euvaldo Chaib)

Expeça-se certidão de honorários à advogada nomeada nos autos (fls. 127), nos termos da tabela DPE/OAB vigente.

Após o trânsito em julgado oficie-se ao TRE, para fins do disposto no artigo 15, III da Constituição Federal; expeça-se guia de execução definitiva e arquivem-se os autos, com as anotações necessárias.

P.I.C.

Francisco Morato, 26 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA